

1500451-18.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500451-18.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083586/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23880141 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 765/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2083586 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

JOAO VITOR DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Data da Audiência:

01/06/2022

Réu Preso

Em 01 de junho de 2022, às 15:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu JOAO VITOR DOS SANTOS, bem como os seus Defensores Técnicos, DR. Luis Carlos Pansonatto Junior OAB 440857/SP e DR Marco Antonio Godoi Sperandio OAB 395509/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Luiz Andrade Silva Junior (GCM), Keila Correa de Souza, Jhenifer Vitória da Conceição de Paula e Julio Gonçalves Machado Queiroz (GM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, pelo representante do Ministério Público foi dito: "MM^a. Juíza, com fundamento no art.384 e art.569, ambos do Código de Processo Penal, para a correção na natureza da droga apreendida em poder do réu, a fim de regularizar a persecução penal, ofereço, em audiência, aditamento da denúncia nos

seguintes termos: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado pelo auto de prisão em flagrante, que, no dia no dia 26 de março de 2022, por volta das 21h, na Rua Isaltino Campos Vieira, nº 261 - Vila Angelica, nesta cidade e Comarca de Tatuí, JOÃO VITOR DOS SANTOS, qualificado a fls. 49, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 14 porções de cocaína, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 9,35 gramas, sem autorização e em de acordo com determinação legal e regulamentar, além de 1 aparelho de telefone celular da importância de R\$ 458,00 em dinheiro (auto de exibição e apreensão a fls. 10 e auto de constatação preliminar a fls. 11). (...) Assim é que, efetuada a abordagem, em busca pessoal, os Guardas lograram encontrar 14 porções de cocaína em poder do denunciado, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, drogas que pertenciam a JOÃO VÍTOR e estavam destinadas à venda. (...)". Pela MM Juíza de Direito foi dito: "Recebo o aditamento da denúncia e, não havendo necessidade de produção de provas, prossiga-se". Ato contínuo, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MMª Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu JOÃO VITOR DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, o qual foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia no dia 26 de março de 2022, por volta das 21h, na Rua Isaltino Campos Vieira, nº 261 - Vila Angelica, nesta cidade e Comarca de Tatuí, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 14 porções de cocaína, , com peso bruto aproximado de 9,35 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, trazia consigo as drogas acima mencionadas e permanecia no local da abordagem, que elegeu como ponto, aguardando usuários para promover a venda oportuna. Guardas Civis Municipais estavam em serviço quando receberam informação de um popular dando conta de que JOÃO VITOR estava vendendo drogas nas proximidades do "Bar do Gordo" e forneceu as características de suas vestes (bermuda e camiseta pretas). De imediato, os Guardas se dirigiram para o local indicado e, lá chegando, avistaram JOÃO VITOR cuja vestimenta correspondia àquela descrita na delação e deliberaram pela abordagem. Na ocasião, o réu estava conversando com outros dois indivíduos, que foram liberados após revista pessoal, eis que nada de ilícito com eles foi encontrado. Assim é que, efetuada a abordagem, em busca pessoal, os Guardas lograram encontrar 14 porções de "maconha" em poder do acusado, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, drogas que pertenciam a JOÃO VÍTOR e estavam destinadas à venda. Em poder do acusado, os Guardas ainda encontraram a importância de R\$458,00 em espécie, dinheiro angariado com a venda de entorpecentes que ele promovia naquele local. O réu foi notificado (fls. 72) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 83/93). Assim, por decisão proferida no dia 18 de maio de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 94/100). Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas e, ao final, o acusado foi interrogado, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos termos da exordial, além da decretação da prisão preventiva do réu, enquanto a Defesa Técnica, ao revés, pugnou pela absolvição do réu, sustentando, em apertada

síntese, insuficiência probatória. Folha de antecedentes a fls. 28/29, bem como Certidões a fls. 30/32. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Preliminarmente, faz-se necessário salientar que operação levada a cabo pelos agentes públicos em comento atendeu aos requisitos legais, não violando preceito constitucional ou abrigado em Lei. Ora, distintamente do alegado pelo D. Defensor, os guardas civis municipais, no momento em que notaram o estado flagrancial, não estavam efetuando diligências para investigações preliminares, mas sim realizando patrulhamento rotineiro para prevenir e inibir ações criminosas contra o patrimônio público municipal, atribuição esta lhes conferida por lei ordinária (art. 5º, II, da Lei nº 13.022/2014), a qual regulamentou a competência atribuída em nossa Carta Magna a esta corporação (art. 144, § 8º, da CF). Faz-se mister ressaltar, outrossim, que os guardas civis municipais não extrapolaram suas funções. Deveras, se presente o estado de flagrância delitiva, a atuação de "qualquer pessoa do povo" seria legal, de acordo com a previsão legal insculpida no art. 301 do Código de Processo Penal. Por tal razão, não há óbices para a ação dos guardas civis municipais, os quais, por serem agentes de segurança, não devem se manter inertes diante de patente atividade criminosa. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, bastando a simples conduta para a constituição do elemento material da figura típica penal, o que afasta a dúvida sobre o estado de flagrância delitiva do recorrente. 2. Dessa forma, à luz do art. 301 do CPP, "qualquer do povo" poderia ter efetuado sua prisão em flagrante, aí incluídos os agentes públicos da guarda municipal. 3. Afastada qualquer ilegalidade na custódia provisória decorrente de flagrante delito, afastado está o seu relaxamento. 4. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC: 17645 SP 2005/0066036-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/09/2005 p. 408) (grifos aditados). Acrescente-se que até mesmo o legislador ordinário acolheu este entendimento, pois no art. 5º, inciso XIII, da Lei nº 13022/2014, atribuiu a Guarda Civil Municipal a competência de "garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas", consolidando o entendimento jurisprudencial acima exposto. Pois bem, o pedido ministerial comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 117/119) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 04), manteve-se em silêncio. Em juízo, disse que no dia dos fatos chamou sua prima para ir ao bar, tomaram cerveja no local e logo em seguida chegou a viatura e já o abordou. O GCM Sandro o acusou de trafico e que iria prende-lo, colocou-o na viatura e disse que dessa vez ele seria preso. Não estava com nada. Tanto

o GCM Sandro como os demais guardas estavam conluiados para prejudica-lo. O GCM Sandro já o havia abordado anteriormente. Já foi abordado por trafico. Trabalha de ajudante de motorista. Tem uma filha e é solteiro. Não estava com nenhuma droga, mas o dinheiro lhe pertencia. Não quis falar nada da delegacia, pois estava assustado e queria falar com seu advogado primeiro. O menino que chegou para conversar com eles estava com uma roupa escura. Rapidamente não daria para vê-los no bar, do local que eles se encontravam. Ganhava cem reais por dia de viagem, levava tijolos. Tinha trabalhado na sexta-feira e tinha recebido. No dia que foi preso estava tomando cerveja com sua prima. O réu ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, negou por completo aos fatos. Ocorre que a versão do réu não se mostra consistente ou factível, eis que para acolhida da versão do réu

de que a droga fora plantada para prejudica-lo, demandaria a presunção de que 06 ou 07 agentes de segurança estivessem conluídos para este intento, o que não se verifica. Quanto ao depoimento da prima do réu, há que ser considerado junto com as demais provas colhidas, levando-se em conta que por seu grau de parentesco, certamente deseja ver seu primo absolvido da imputação sofrida. De outro lado, o Guarda Civil Municipal Julio Gonçalves Machado Queiroz, em sede policial (fls. 02), declarou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, durante patrulhamento pelo bairro Vila Angélica, quando foram informados por um popular anônimo de um indivíduo vestindo bermuda preta e camiseta preta e também boné, o qual estaria vendendo drogas pelo "Bar do Gordo". Deslocaram para o local, com apoio da Romu, onde chegando próximo ao bar, avistaram um indivíduo com as características da informação. O acusado foi abordado, o qual estava conversando com dois sujeitos, que também foram abordados e revistados. Com esses dois sujeitos, nada de ilícito foi encontrado, sendo liberados pelo local. Em revista pessoal, com o acusado, no bolso da bermuda, foram encontrados 14 pinos de cocaína e R\$ 458,00 em dinheiro (sendo 4 notas de cem reais e o restante em notas diversas). Instada, o acusado negou que estava vendendo drogas e falou também que não portava nenhum tipo de drogas. O acusado falou que já possuía um tráfico de drogas. Afirmou que o local é conhecido pela venda de drogas. Em juízo, confirmou terem recebido denúncia anônima que descrevia as vestimentas do réu e o local em que ele estaria traficando. Junto com o réu estavam ainda outros dois indivíduos que foram abordados e liberados. Com o réu foram localizadas as poções de cocaína. Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Luiz Andrade Silva Junior, em sede policial (fls. 03), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, disse que em patrulhamento pelo beirro, foram abordados por um indivíduo que descrevia um indivíduo moreno, trajando vestimentas escuras, que vendia entorpecentes no bar do gordo. Pediram apoio da Romu, foram ao bar, identificaram o indivíduo que estava acompanhado de outros dois indivíduos. Apenas o réu estava com entorpecentes, além da quantia de R\$458,00. Salvo engano participou da diligência a viatura da Romu com 3 ou 4 pessoas e eles que são do canil. Não se recorda se o GCM Sandro estava no dia dos fatos, mas ele é da equipe. No momento da abordagem não havia mulher com o réu, depois chegou uma. Nenhuma mulher presenciou a revista pessoal dele. O bar é aberto, como se fosse avarandado, assim identificaram o réu de dentro da viatura. Dá para ver quem está dentro do bar. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu. Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuarão a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Por sua vez, a testemunha Keila Corrêa de Souza, em sede judicial, disse que é ex-sogra do réu, que o réu dizia que os guardas sempre o abordavam em especial um de nome Sandro e que era ameaçado que um dia seria pego. Finalmente, a testemunha Jhenifer Vitória

da Conceição de Paula, em juízo, disse que é prima do réu, que naquele dia combinaram de sair a noite, passou na casa dele e antes de ir combinaram de passar no bar para tomar uma cerveja. Estavam no bar, chegaram alguns meninos e conversaram com ele. Logo chegaram dois camburões, foram direto para abordá-los. Como não havia guarda mulher, ela não foi abordada, apenas os meninos. Eles conversaram algo, o policial Sandro fez algumas perguntas para ela. Depois colocaram Joao Vitor no carro, ele começou a se debater e dizer que não estava com nada. Um dos policiais disse - "que da primeira ele não foi, mas da segunda ele iria". Quem está do lado de fora não enxerga nitidamente dentro do bar. Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos agentes de segurança, os quais narraram verossimilmente, a apreensão das drogas com o acusado; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 117/119), o qual atestou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; 4) a exata correspondência do acusado e suas vestimentas com o do traficante delatado anonimamente; e 5) a informação dos guardas, de que, informalmente, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não

ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é

aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, *Elementos de Direito Processual Penal*, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, *Código de Processo Penal Comentado*, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, *Da Prova Penal*, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. *Prova Penal*, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., *verbi gratia*, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 117/119) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. De fato, observo que o apontamento criminal retratado a fls. 30 (Proc. 1501525-44.2021.8.26.0571) se refere a ação penal em curso e, a despeito de entendimento pessoal diverso dessa Magistrada, observo que a jurisprudência se consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a valoração negativa em primeira fase (Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisória: “embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.” (TJSP; *Apelação Criminal* 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). Desse modo fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante à mingua de outras causas modificadoras da pena a incidir. Convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado

a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, trata-se de réu que está sendo processado em outro feito pelo mesmo delito que se apura nos autos, com sentença recorível (fls. 30 - Proc. 1501525-44.2021.8.26.0571), o que é elemento caracterizador de dedicação a atividades criminosas, restando inviabilizada a concessão da benesse em questão. Naquele, o réu fora agraciado com o benefício do §4, artigo 33, da lei em comento. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: "É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006." (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33, § 3º, c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime fechado, considerando a personalidade do acusado e a gravidade concreta do delito, refletida pela quantidade e diversidade da droga que seria traficada. A tão só quantidade de pena aplicada obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A tão só quantidade de pena inviabiliza a concessão do sursis. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu JOÃO VITOR DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, trata-se de réu que está sendo processado em outro feito pelo mesmo delito que se apura nos autos (fls. 30 - Proc. 1501525-44.2021.8.26.0571), de modo a revelar que, acaso solto, tornará a delinquir, razão pela qual a manutenção de sua prisão cautelar é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Diante da condenação, fica ainda obrigado o réu a recolher custas de 100 (cem) UFESP's, na forma do art.4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois o réu constituiu advogado (fls. 74), signo presuntivo de riqueza que revela a capacidade dele para suportar o ônus financeiro das custas processuais. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor referente às custas processuais e o total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 61) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 458,00 em dinheiro - fls. 10) em favor da União, apropriados os bens

ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP." Pelos Defensores do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo os Defensores, desde já, intimados a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões e contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA